

第54問

甲は乙にAの殺害を依頼し、乙はこれを引き受けた。甲は、犯行準備のための資金として乙に現金100万円を手渡し、A殺害後には報酬としてさらに200万円を支払うことを約束した。その後、乙は、その妻丙から「甲なんかのために、危ない橋を渡ることはない。」と説得され、殺害を思いとどまり、丙と二人でその100万円を費消した。そのころ、Aは既に重病にかかっており、しばらくして病死したが、乙はこれに乗じて、甲に対し自分が殺害したように申し向けて約束の報酬を要求し、現金200万円を受け取った。その夜、乙は、丙にこれを自慢話として語り、同女にそのうちの100万円を与えた。

乙及び丙の罪責を論ぜよ。

(旧司法試験 平成10年度 第2問)

第1 乙の罪責

- 1 甲から殺害準備のため手渡された100万円を費消した行為
横領罪（252 I）の成否が問題となる。

論点となるのは、金銭であること（**論点** 「他人の物」（252 I）の意義（寄託された金銭等） 司H19,予H27,旧H10-2,H14-2,H20-2）、不法原因給付物（民708）であることから、「他人の物」であるといえるか否か（**論点** 不法原因給付（不法契約）と財産罪～横領 旧H10-2）である。

 239 頁  111 頁

 262 頁  134 頁

前者については肯定的に解するのが判例であり（最判昭26.5.25【百選Ⅱ64】等）、後者についても肯定的に解するのが判例であると解されていた（最判昭23.6.5【百選Ⅱ63】、最判昭26.5.25【百選Ⅱ64】）が、民事判例の登場によって流動的な面がある（最大判昭45.10.21【民法百選Ⅱ82】）。

- 2 Aを自分が殺害したかのように欺き、甲から200万円を受け取った行為

1 項詐欺罪（246 I）の成否が問題となる。

ここでも不法原因給付であることとの関係が問題となる（**論点** 不法原因給付（不法契約）と財産罪～詐欺・恐喝 旧H1-2,H3-2,H8-2,H10-2,H17-2）。この場面では不法原因給付であることとの抵触関係が生じないとして、肯定説をとるのが一般的である。判例も理論構成は不明であるものの、肯定説をとる（最判昭25.7.4【百選Ⅱ46】）。

 262 頁  133 頁

第2 丙の罪責

- 1 甲から殺害準備のため手渡された100万円を費消した行為

丙には乙との十分な意思連絡及び正犯意思が認められるから、横領罪の共同正犯（60）となるとみてよいだろう。また、横領罪は真正身分犯であるから（大判明44.5.16）、共犯と身分の問題は生じるが（**論点** 共犯と身分～65条1項と2項の関係 司H24,予H27,旧H10-2,H19-2、**論点** 共犯と身分～65条1項の「共犯」の意義 司H24,予H27,旧H10-2）、真正身分犯には65条1項が適用され、また、同項の「共犯」には共同正犯を含むと解するのが判例である（大判大4.3.2）。

 156 頁  63 頁

 156 頁  63 頁

- 2 丙が、乙が甲から騙し取った200万円のうち100万円を無償で譲り受けた行為

- (1) 盗品等無償譲受け罪（256 I）の成否が問題となる（**論点** 不法原因給付（不法契約）と財産罪～盗品等関与罪 旧H10-2）。

 263 頁  134 頁

ここでも、100万円は不法原因給付物であり甲に返還請求権が認められないこととの関係が問われる。

この点については判例の立場が明確ではなく、学説も、本犯者に対する財産犯の成否やその理由付けを巡って様々な見解が主張されている。

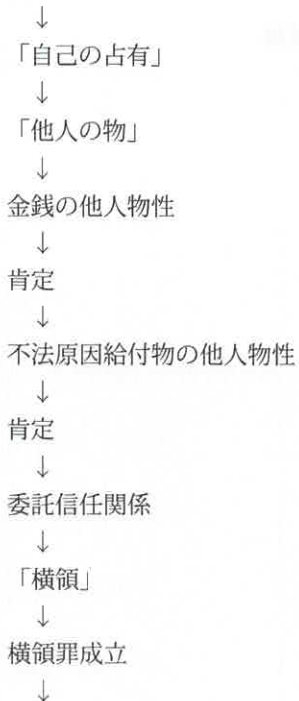
- (2) 乙と丙は夫婦であるから、257条1項の適用がある（**論点** 257条1項における親族関係は犯人と誰との間に必要か 旧H10-2）。同条について、「本犯と赃物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、赃物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものである」と解するのが判例だからである（最決昭38.11.8）。

 261 頁  132 頁

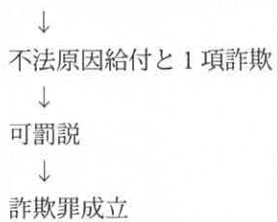
答案構成

第1 乙の罪責

1 横領罪（252 I）の成否

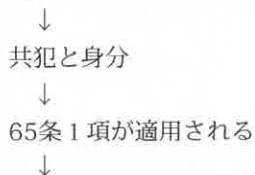


2 詐欺罪（246 I）の成否

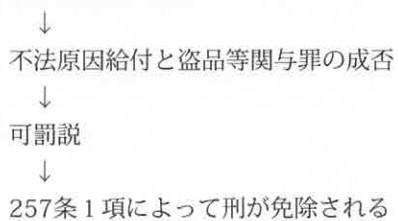


第2 丙の罪責

1 横領罪の共同正犯の成否



2 盗品等無償譲受け罪（256 I）の成否



第3 罪数

- 1 乙には横領罪の共同正犯と詐欺罪が成立し、両者は併合罪（45前段）となる

↓

- 2 丙には横領罪の共同正犯と盗品等無償譲受け罪が成立し、両者は併合罪となる。盗品等無償譲受け罪は刑が必要的に免除される

第1 乙の罪責

1 (1) 乙が、甲からA殺害準備のため手渡された100万円を費消した行
2 為につき、横領罪(252条1項)の成立が考えられる。

3 (2)ア 乙には100万円につき「自己の占有」がある。

4 イ もっとも、民法上、金銭の所有権は占有と一致すると解されてい
5 ることから、「他人の物」に当たらないとも考えられる。

6 しかし、金銭における所有と占有の一致が民事法領域で認められ
7 ているのは、多数人間を金銭が流通していく取引の動的安全の保護
8 を目的とするものだからである。そうだとすれば、寄託者と受託者
9 の間での静的安全の保護が問題になる刑法領域において同一に考え
10 るべき根拠はない。

11 したがって、寄託された金銭も「他人の物」に当たると考える。

12 このように金銭も横領罪の客体となるとしても、本問100万円
13 はA殺害準備の資金であるから、不法原因給付物に当たり、委託者
14 甲に民法上返還請求権が認められないと考えられる(民法708条
15 本文参照)。そこで、このような観点から、本問100万円が「他
16 人の物」といえるかが問題となる。

17 この点について、民事法的には法的保護に値する利益がない場合
18 であっても、不法な手段によって財産法秩序を乱す行為を容認する
19 ことは、私人の正当な権利の実現を不能ならしめることになる。

20 そうだとすれば、刑法上の他人物性は領得行為に対して刑法上保
21 護すべき利益があるか否かという観点から判断すべきである。そし
22

1

1 て、不法原因給付物でも、当該物を委託の趣旨に反して費消すれ
2 ば、財産罪の保護すべき財産秩序が乱れることに変わりはない。

3 したがって、不法な原因に基づいて給付された金銭も「他人の
4 物」といえると考ええる。

5 よって、上記100万円は「他人の物」に当たるといえる。

6 ウ また、甲と乙には、委託信任関係も認められる。なお、この委託
7 信任関係はA殺害にかかる違法なものであるものの、上記の通り、
8 財産秩序維持の観点からはいったん保護すべきである。

9 エ 最後に、乙が寄託された金銭をほしいままに費消していることか
10 ら、不法領得の意思の発現として、「横領」行為も認められる。

11 (3) 以上より、乙に横領罪が成立する。

12 2 次に、乙が、Aを自分が殺害したかのように欺き、甲から200万
13 円を受け取った行為につき「人を欺いて財物を交付させた」ものとし
14 て、詐欺罪(246条1項)の成立が考えられる。

15 確かに、200万円も殺害の報酬として支払われているので、民法
16 上、甲には返還請求権が認められない(民法708条本文参照)。そう
17 だとすれば、記述されざる構成要件要素としての財産上の損害の発生が
18 認められないとも考えられる。

19 しかし、甲は乙の欺く行為がなければ、200万円を交付しなかった
20 のであり、当該欺く行為に基づいて不法原因給付がなされたという関係
21 がある。そうだとすれば、交付以前においては当該財物には何ら不法は
22 存在しなかったというべきである。

2

したがって、不法原因給付該当性は、詐欺罪の成立に影響を与えないものと解すべきである。

以上より、乙には詐欺罪が成立する。

第2 丙の罪責

1 丙が乙と二人で100万円を費消した行為につき、横領罪の共同正犯(60条)の成立が考えられる。

丙は「甲なんかのために、危ない橋を渡ることはない。」と乙を説得し、100万円の費消を促しただけではなく、自ら費消に関与しており、十分な利益の帰属も認められるから、乙と「共同して犯罪を実行した」といえる。

また、横領罪は、他人の財物の占有者であることを要する真正身分犯であるところ、65条1項はその文言上真正身分犯の成立・科刑を定めたものと考えられるので、横領罪にも適用される。そして、65条1項の「共犯」には、共同正犯が含まれると考える。非身分者は、身分者の行為を利用することにより保護法益を侵害することができるからである。

以上より、丙には横領罪の共同正犯が成立する。

2(1) さらに、丙が、乙が甲から騙し取った200万円のうち100万円を無償で譲り受けた行為につき、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた」として、盗品等無償譲受け罪(256条1項)が成立することが考えられる。

この点について、盗品等に関する罪の本質は、所有者の物に対する

3

追求権の実行を困難にする点にあるところ、100万円は不法原因給付物であり、甲に返還請求権が認められないことから、丙に盗品等無償譲受け罪は成立しないようにも思われる。

しかし、盗品等に関する罪の本質は、被害者の追求権侵害に加え、本犯助長性にも求めることができる。そうだとすれば、被害者に返還請求権が認められないとしても、本犯助長性が認められる以上は、本罪の成否には影響がないというべきである。

よって、上記100万円が不法原因給付物であったとしても、丙に盗品等無償譲受け罪が成立する。

(2) そうだとしても、丙は乙の「配偶者」であるから、257条1項により刑が免除されないか。

同条項は、身内の財産犯人のために盗品等に関与することは期待可能性が減ずることを理由とする一身の処罰阻却事由であることから、親族関係は盗品等関与罪の犯人と本犯者との間に必要となる。

本問では、上記のように、丙は本犯者である乙の「配偶者」であるから、257条1項により、刑は必要的に免除される。

第3 罪数

1 乙には横領罪の共同正犯と詐欺罪が成立し、両者は併合罪(45条前段)となる。

2 丙には横領罪の共同正犯と盗品等無償譲受け罪が成立し、両者は併合罪となる。ただし、盗品等無償譲受け罪については、刑が必要的に免除される。

以上

4